

1501487-37.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... nos bolsos Ele confessou que estava no tráfico e indicou que subindo as escadas, no lado esquerdo, tinha uma sacolinha com as demais drogas e uma anotação da contabilidade do tráfico. Reconhece o réu, e não o viu no local antes.

O réu, extrajudicialmente (fl.08), respondeu que não tem envolvimento com o tráfico de drogas, que reside na primeira casa do escadão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501487-37.2021.8.26.0537 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501487-37.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201951/2021 - DISE-

DEL.SEC.DIADEMA, 19264058 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 67/21/301 - DISE-

DEL.SEC.DIADEMA, 2201951 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wesley Alves da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

VISTOS.

WESLEY ALVES DA SILVA, qualificado às fls. 08/10, está sendo processado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei de Tóxicos, porque no dia 27 de julho de 2021, por volta das 12h30, durante o período de calamidade pública ocasionada pela pandemia do Covid-19, no escadão existente na Rua Almirante Cockrane, altura do nº 182, Vila Conceição, nesta cidade de Diadema, trazia com ele, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 24 embalagens plásticas contendo 12,11g da droga cocaína, 19 embalagens plásticas contendo 3,03g da mesma

droga, na forma de crack e 16 embalagens plásticas contendo 77,29g da droga maconha, além de oito frascos contendo 260ml de cloreto de metileno (lança perfume), conforme auto de apreensão e exibição de fls. 23/24 e laudo de constatação provisória de fls. 35/37, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl. 56/60). A denúncia foi recebida em 08/10/21 (fl.115), sem proposta de transação penal. Seguiu-se com a notificação (fl.104) e citação do réu (fl. 135), a quem foi nomeado Defensor Público que ofertou defesa inicial as fls. 112/113.

Em audiência uma foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas Partes, e interrogado o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, entendendo que a pena base deva ser fixada acima do mínimo legal diante da quantidade e variedade de drogas altamente nocivas como o crack e cocaína, sem possibilidade de redução da pena nem sua substituição, a cumprida em regime fechado, sem possibilidade de apelo em liberdade.

Já o d. Defensor Público pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, fixando-se regime mais brando e substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, com direito de apelo em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem no auto de exibição e apreensão de fls.23/24 e 33, auto de constatação e definitivo, ambos positivos para as drogas maconha, cocaína e cloreto de metileno (respectivamente às fls.35/37, 88/90 e 131/133). No mais, observo que o lança perfume ou cloreto de etila, assim como o cloreto de metileno ou diclorometano, são insumos químicos usados na fabricação e síntese de entorpecentes, e portanto sujeitos a controle do Ministério da Justiça (Portaria Anvisa 344/98).

A autoria é incontestada conforme prova que sigo analisando.

Os policiais afirmaram em solo pré-processual (fls. 05 e 06) que diligenciaram com uma viatura descaracterizada até a Rua Almirante Cockrane, próximo ao número 182, Vila Conceição, Diadema/SP, onde existe um escadão que é um conhecido local de traficância de drogas. Pararam a viatura com visão ao início do escadão onde costuma ficar o vapor (pessoa responsável pela venda da droga), de onde puderam visualizar um indivíduo branco, vestindo camiseta preta, parado no local, parecendo estar nervoso, entrando e saindo de um bar (que fica ao lado do escadão) e voltando para o início do escadão várias vezes. Resolveram aborda-lo. Identificando como sendo WESLEY ALVES DA SILVA, e revistado, foi encontrado na sua posse dois invólucros de substância assemelhada a maconha e dois invólucros de substância assemelhada a cocaína. Ao ser questionado, assumiu a traficância, indicando o local (subindo o escadão, primeira entrada a esquerda, sob uma escada de metal) onde havia uma sacola plástica com mais drogas escondidas.

Em juízo o policial Willian Carrieri reiterou que o local é conhecido como ponto de tráfico, e sabe que a namorada do réu também trafica, como está na denúncia. Fizeram uma campana e o acusado entrava e saía de um bar. Desconfiaram, e por isso

o abordaram. Na posse dele estavam quatro porções de drogas. Ele confessou informalmente que estava traficando, e indicou ao lado do barzinho, uma sacolinha com o restante das porções de crack, cocaína, maconha e lança perfume. Reconhece o réu e já o viu antes na viela. São feitas várias denúncias de tráfico no local e também vão até lá porque o local é conhecido como ponto de tráfico, e em uma dessas denúncias dizia que Caroline também trafica, e sabem que ela é namorada do réu, tanto que já os viram juntos em outras vezes. Na sacola, subindo a viela, embaixo de uma escada, também tinha uma anotação do tráfico.

O policial Adriano Ponte trouxe em juízo a mesma versão que seu parceiro, de que havia várias denúncias do local como sendo um ponto de venda de drogas. Fizeram uma breve campanha e visualizaram o réu entre o escadão e um bar, indo e vindo. Resolveram aborda-lo e com ele havia entorpecentes nos bolsos. Ele confessou que estava no tráfico e indicou que subindo as escadas, no lado esquerdo, tinha uma sacolinha com as demais drogas e uma anotação da contabilidade do tráfico. Reconhece o réu, e não o viu no local antes.

O réu, extrajudicialmente (fl.08), respondeu que não tem envolvimento com o tráfico de drogas, que reside na primeira casa do escadão e que nesta data acordou no final da manhã e desceu o escadão indo até o bar que fica ao lado, para comprar um salgadinho e um refrigerante, e quando saiu do estabelecimento foi abordado e trazido até esta delegacia. Declarou que não portava drogas ou quaisquer coisas ilícitas, mas que ainda assim foi conduzido até esta delegacia. Declarou que foi preso em 2015 por roubo, saindo do sistema prisional no ano de 2020 e que desde então não consegue emprego, que se mantém fazendo bicos informais.

Sob o crivo do contraditório o acusado alegou ter acordado por volta das nove horas da manhã e dias antes os policiais tinham ido lá e não pegaram ninguém e invadiram sua casa e de sua esposa perguntando se tinha algo de ilícito. Eles entraram, procuraram, não acharam nada, nem os outros policiais acharam nada nas vielas. Tiraram fotos sua e de sua mulher. No dia dos fatos, foi no bar na rua de baixo de onde mora, comprou refrigerante e um salgadinho. Ao voltar para casa, foi abordado. Deixou suas coisas em cima do capô do carro, o empurraram para dentro daquele, e lhe agrediram, quatro policiais, e queriam saber onde estavam as drogas, e respondeu que não mexia com isso. Os policiais foram para o escadão enquanto prosseguia sendo enforcado dentro do carro por um policial que ficou consigo. Nisso tocou o celular de um dos policiais e então lhe perguntaram de novo sobre as drogas, e disse que não mexia com isso, até que um policial voltou do escadão com uma sacolinha dizendo que era sua, e assim foi preso. Não chamou o dono do bar para ser sua testemunha porque não teve contato com sua esposa e depois ficou tarde. E questionado sobre a versão de hoje que não foi dita em solo policial, disse que falou tudo o que disse hoje no DP. Trabalhava fazendo bico com seu sogro, na marcenaria, mas no dia dos fatos não foi trabalhar, e sua esposa também não estava trabalhando no dia, embora ela olhe crianças.

Logo, os depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais.

Tanto que o réu confirmou, extrajudicialmente, aos policiais, que estava traficando, e mostrou onde estava a sacola contendo as demais drogas, embaixo de uma escada, próxima a si. Ora, se não fosse o réu indicar aos policiais onde estava o restante das drogas, estas não teriam sido apreendidas, mas apenas as encontradas consigo, que eventualmente poderiam indicar serem para mero uso.

Contudo, o réu não conseguiu demonstrar o por ele alegado, ou seja, de que havia comprado apenas salgadinho e refrigerante no bar de onde saiu antes de ser abordado, posto que sequer arrolou um funcionário do local a corroborar seu álibi.

Nem mesmo sua esposa, que teria presenciado a dita invasão dos policiais em sua casa dias antes, fato grave e sequer mencionado tempestivamente ao Defensor Público e sequer a autoridade policial. Assim como outro fato gravíssimo só trazido à baila hoje pelo acusado, qual seja, a de que sofreu agressão física por parte de quatro policiais que até o enforcaram, embora o laudo pericial de fl. 148 não trouxesse nenhuma lesão no preso, tanto que ao que consta, não foi ajuizado pedido administrativo contra as ditas irregularidades dos policiais junto à Corregedoria competente.

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, HC 76.608-0).

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo, guardar e ter em depósito, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Mesmo que o réu estivesse sem dinheiro, o que não indica que ele não estivesse traficando, e sim que não foi apreendido dinheiro, talvez porque o que ele tivesse, gastou no bar, como ele mesmo disse.

Assim, como visto, o réu não fez prova de nada do que alegou hoje, ou seja, de que os policiais já tinham ido em sua casa antes, nem de que estivera no bar para comprar refrigerante e salgadinho para si, a indicar que não estaria traficando. Não arrolou nem sua esposa nem o dono do bar, e não há notícia, reclamo, da tal invasão do domicílio anterior.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), as anotações apreendidas, são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, assim como a quantidade de narcótico apreendido que não reputo excessivo (51 no total), mas diante da diversidade e alta periculosidade delas, como a cocaína, crack, e além delas a presença de maconha e lança perfume, pelo princípio da proporcionalidade e para uma mais justa individualização da pena, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo, qual seja, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fl. 42/43) a qual compenso com a atenuante da confissão, ainda que não reiterada em juízo, mas dela me valho para também embasar a condenação, pois como já visto, se não fosse pelo réu indicar aos policiais onde a maior parte das drogas estavam, elas não

teriam sido localizados nem apreendidos os 51 invólucros totais e sim quatro, de maneira que a pena resta inalterada nesta etapa. Quanto à agravante do art. 61, II, "j", do CP, embora os fatos tenham se dado em época da pandemia pelo Covid 19, entendo não haver prova cabal de que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, dessa situação especial à prática delitiva, ou que tenha se valido da facilidade que dela decorreu como: dificuldade de policiamento, menor cuidado por parte da vítima ou uma situação dramática pela qual passasse, incapacitando-a total ou parcialmente de defesa, por estar fragilizada ou adoentada, a merecer maior grau de reprovabilidade da conduta, dada a ausência de solidariedade humana e frieza moral. Ademais, não houve invasão da esfera de individualidade de terceira pessoa. Neste sentido vide: Por unanimidade, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a agravante de crime cometido em período de calamidade pública, conforme o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois, segundo o relator, desembargador Andrade Sampaio, "não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19" (TJ-SP / Proc. 1512067-20.2020.8.26.0228).

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Nem de redução, porque o réu é reincidente, ainda que não específico, o que a lei não exige, somado ao encontro das anotações típicas da contabilidade do tráfico a indicar maior envolvimento com a mercancia ilícita. Incabível a benesse do art. 44 do CP ao réu por ausentes os requisitos objetivo (pena superior a 4 anos) e subjetivo (réu é reincidente).

Some-se a isso o fato de que : ... O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 10, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Fixo o regime prisional fechado, por conta da variedade das drogas, especialmente a existência de crack, somado à reincidência do agente. Ora: Segundo entendimento do STJ já firmado, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e da quantidade da droga. Assim, o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar tais circunstâncias.

Vedo o recurso em liberdade, sendo incongruente soltar o réu, ora condenado a regime que o manterá preso para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de seis meses, e sem direito sequer à progressão de regime, considerando a prisão do réu por menos de três meses.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC nº 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória, consoante estabelecido pela Resolução n.º 113, do Conselho Nacional de Justiça

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra WESLEY ALVES DA SILVA, qualificado às fls. 08/10, como incurso no artigo 33 “caput” da Lei de Tóxicos e o faço para condená-lo à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Sem condenação nas custas e despesas processuais por ser assistido pela DPE.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias. Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA